

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 23/2557

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ผู้ฟ้องคดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 มาตรา

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 มาตรา

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง
ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 มาตรา

คดีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เห็นว่า คดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การว่า ขณะผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งยศแล้วได้นำใบสำคัญ สด. ๙ แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายไปขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ จนทำให้เจ้าหน้าที่สัสดีผิดหลงออกใบสำคัญ สด. ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจำการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบข้อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งเป็นข้อบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหาร ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระ

ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กรณีจึงเป็นเรื่องวินัยทหารตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ข้อพิพาทระหว่าง
โจทก์และจำเลยในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่
ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นคดี
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๓/๒๕๕๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง

ศาลปกครองกลาง

ระหว่าง

ศาลแพ่ง

การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๐๐/๒๕๕๕ กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยเมื่อปี ๒๕๓๑ ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรักษาราชการอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๒๐/๓๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ และต่อมาได้รับพระราชทานยศร้อยตรี ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ กล่าวคือ ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ นับแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป และในปี ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการรับราชการทหาร ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๗๐/๓๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๒ ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีผู้ร้องเรียนต่อกระทรวงกลาโหมว่า การเข้ารับราชการทหารของผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปตามกฎหมาย โดยใช้หลักฐานทางทหารไม่ถูกต้อง กระทรวงกลาโหมจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งจเรทหารบกเป็นกรรมการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารกองประจำการกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถหา

พยานหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวนได้อย่างครบถ้วน กับทั้งไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ปากคำและแสดงพยานหลักฐาน แต่ได้สรุปรายงานการสอบสวนโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมาเมื่อปลายปี ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ดำเนินการถอดชั้นยศของผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งเรียกคืนเบี้ยหวัด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินและสมัครเข้ารับราชการทหารโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามที่มีการร้องเรียนไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะถอดถอนชั้นยศและเรียกคืนเบี้ยหวัด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาและไม่เคยมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดในกรณีดังกล่าว เมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยดำเนินการสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง โดยไม่มีการเรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ และในระหว่างนั้น สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยถอดถอนชั้นยศและเรียกคืนเบี้ยหวัดคืนจากผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๔๔/๕๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการสอบสวน กรณีการบรรจุเข้ารับราชการการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และการแต่งตั้งยศทหารของผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้การและนำส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนดหรือให้นัดหมาย วัน เวลา มาให้การหรือส่งเอกสารหลักฐานในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบ

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นในการสอบสวนพร้อมขอเลื่อนกำหนดวัน
ให้การ แต่คณะกรรมการสอบสวนยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ปากคำแล้วรีบสรุปสำนวน
การสอบสวนเสนอให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่
๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารใบสำคัญ สด. ๙
ที่ชำรุดสูญหาย ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๑ อันมีข้อความสาระสำคัญเป็นเท็จไป
ประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการ ณ จังหวัดนครนายก จนทำให้เจ้าหน้าที่สัสดี
ผิดหลงออกไปสำคัญ สด. ๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ขึ้นทะเบียนกองประจำการ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำที่ละเมิดศีลธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียม
ทหารของนายทหารสัญญาบัตร เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แห่งตน เป็นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง
ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งไม่ได้รับ
ฟังคำให้การของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีมีพฤติการณ์
หรือเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีและหวังผลทางการเมือง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีขาดสมาชิก
ภาพในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน
ได้อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการโดยถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารใบสำคัญ สด. ๙
ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเอกสารเท็จเป็นเอกสารที่ออกโดยสัสดีซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจ
หน้าที่และไม่มีส่วนเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารดังกล่าว เมื่อมีการลงรายการผิดก็เป็น
ความบกพร่องของสัสดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการรับราชการทหาร
กองประจำการเป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ ตาม
คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๒๗๐/๓๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่
อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร เนื่องจากทหารที่อยู่ในบังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้วยวินัยทหารคือ กองประจำการและทหารประจำการ ส่วนทหารกอง
เกินและทหารกองหนุนนั้น เป็นทหารที่ไม่ได้รับราชการและมีได้อยู่ประจำหน่วย

ทหาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดีว่ากระทำความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นคำสั่งเกี่ยวกับวินัยทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อยุติชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารใบสำคัญ สด. ๙ ฉบับใบแทนลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๑ ที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๑ อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นเอกสารเท็จไปจดแจ้งต่อเจ้าพนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก เพื่อให้ได้รับสิทธิรับเวลารับราชการทหารในกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยทหารร้ายแรงตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจปลดออกจากราชการหรือถอดจากยศทหารได้ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีจะเป็นนายทหารนอกราชการ แต่การกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการซึ่งอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ที่ไม่มีอายุความและไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางปกครองเนื่องจากกระทำผิดวินัยกับผู้ที่เป็นนายทหารนอกราชการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบข้อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ว่าด้วยการแบ่งประเภท

นายทหารสัญญาบัตรที่กำหนดให้นายทหารนอกราชการต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ คำสั่งและแบบธรรมเนียมทหาร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทราบรายงานผลการสอบสวนจึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยให้มีผลนับแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นวันที่กระทำผิดจึงกระทำได้ ผู้ฟ้องคดียังคงมีสถานะเป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดทหารบกกรุงเทพ กระทรวงกลาโหม โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ (มีผลเท่ากับเปลี่ยนแปลงสถานภาพและประเภทนายทหารของผู้ฟ้องคดีออกจากรายการประเภทที่ ๑ เป็นนายทหารกองหนุนหรือนายทหารประเภทที่ ๔) นอกจากนี้ คณะกรรมการที่กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีมาให้การหรือให้ปากคำหรือนำส่งพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามสมควร และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และกระบวนการออกคำสั่งเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมและแบบธรรมเนียมการปฏิบัติทางทหาร คดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองขอให้ยกฟ้อง

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่ากรณีตามคำฟ้องเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ เมื่อพิเคราะห์มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ จะเห็นได้ว่า ทหารที่ต้องอยู่ในบังคับที่จะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ต้องเป็นทหารตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้แก่ ข้าราชการทหารซึ่งคือทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุใน

ตำแหน่งอัคราทหาร ทหารกองประจำการ รวมทั้งนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองเกินหรือกองหนุนที่ถูกเรียกเข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาการทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมและในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง และปรากฏจากการไต่สวนคู่กรณีของศาลได้ความว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๒๐/๓๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๙/๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ เป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการทหารและผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งทั้งสองฉบับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้ง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๒๐/๓๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ที่บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ และให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๙/๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ เฉพาะที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑ โดยผลของคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานะเป็นข้าราชการทหารตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ส่วนประเด็นว่าคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น

เป็นประเด็นในเนื้อหาของคดีที่จะต้องวินิจฉัยต่อไป จึงเห็นได้ว่า คดีนี้โดยเนื้อหาของเรื่องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้ง การปลดจากประจำการตามที่ผู้ฟ้องคดีขอลาออกจากราชการ และการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกลาโหมตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการดำเนินการทางวินัยทหาร ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจและเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีและขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีใช่เป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลเหตุที่มีการปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารใบสำคัญ สด. ๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นฉบับที่แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายอันมีข้อความเป็นเท็จ ดังนั้นในเบื้องต้น

ประเด็นที่ว่าข้อความในเอกสารใบสำคัญดังกล่าวมีข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่จึงเป็นประเด็นสำคัญ และเมื่อพิจารณาประกอบกันว่าแม้จะรับฟังได้ว่ากระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาถั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการก็ตาม แต่หากข้อความในเอกสารใบสำคัญดังกล่าวยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ ข้อสงสัยในเอกสารดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่และอาจถูกนำไปอ้างให้เกิดปัญหาเป็นคดีอีกไม่สิ้นสุด ข้อความในเอกสารใบสำคัญดังกล่าวมีข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ จึงเป็นประเด็นหลักที่สำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยโดยศาลเสียก่อนในลำดับแรก เมื่อได้ความชัดเจนแล้วจากนั้นจึงจะมีการวินิจฉัยว่าคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในลำดับต่อไปอันเป็นประเด็นรอง ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยว่าเอกสารใดเป็นเอกสารเท็จหรือไม่ มีการใช้เอกสารอันเป็นเท็จในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือไม่นั้น เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ส่งผลให้ต้องมีการวินิจฉัยในคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ประเด็นในคดีหลักส่วนหนึ่งที่ยังโต้แย้งกันอยู่มีว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือไม่ ซึ่งควรได้รับการวินิจฉัยในคดีหลัก ไม่ควรได้รับการวินิจฉัยในชั้นวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เพราะอาจมีผลครอบงำให้คดีต้องพิพากษาตาม ทำให้ขาดความมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากศาลที่จะต้องพิจารณาพิพากษาในคดีหลักยังคงเป็นศาลเดียวกันกับศาลตามความเห็นซึ่งอยู่ในระดับหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารหรือไม่ก็มีความจำเป็นที่ต้องนำกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารมาพิจารณาวินิจฉัยว่าใช้บังคับแก่กรณีหรือไม่ ซึ่งก็เป็นกรณีที่อยู่ในความหมายของคำว่า การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) นั้นเอง ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายกรณีผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารเท็จไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการ จนทำให้เจ้าหน้าที่สัสดีผิดหลงออกไปสำคัญ สด. ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจำการให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำที่ละเมิดศีลธรรม จริยธรรม และแบบธรรมเนียมทหารของนายทหารสัญญาบัตร เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แห่งตน เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งไม่ได้รับฟังคำให้การของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) บัญญัติให้คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีจึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า การฟ้องเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารหรือไม่

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๔ บัญญัติว่า "วินัยทหารนั้น คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร" ซึ่งแบบธรรมเนียมของทหาร ได้แก่ บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง และหนังสือต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาออกหรือวางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มาตรา ๗ บัญญัติว่า "ทหารผู้ใดกระทำผิดต่อวินัยทหาร จักต้องรับทัณฑ์ตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้และอาจต้องถูกปลดจากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหาร" และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๕ บัญญัติว่า "วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหมกำหนด" เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามคำให้การว่า ขณะผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งยศแล้วได้นำใบสำคัญ สด. ๙ แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายไปขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ จนทำให้เจ้าหน้าที่สถิติผิดหลงออกไปสำคัญ สด. ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจำการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบข้อบังคับทหาร ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหาร สัญญาบัตร ซึ่งเป็นข้อบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหาร ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กรณีจึงเป็นเรื่องวินัยทหาร ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัย

ทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง
(๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒
แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ฟ้องคดี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(กฤษฎา เจริญพานิช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

()

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง